

1011070-61.2021.8.26.0066
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Práticas Abusivas
Magistrado: Douglas Borges da Silva
Comarca: Barretos
Foro: Foro de Barretos
Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... vez que se trataria em tese de crime de furto de energia (art. 155, § 3º, do CP). A polícia existe para isso: prevenir, reprimir crimes e apurá-los. E isso 24 horas por dia. Acionada, caberia a ela promover a perícia no tal medidor e apurar a conduta do consumidor, independentemente de solicitação prévia do consumidor e em tempo não distante da apuração.

Não pretendendo acionar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

3ª Vara Cível

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1011070-61.2021.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1011070-61.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente e Reconvinte:

Ivan Menezes e Silva e outro

Requerido e Reconvindo:

Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Douglas Borges da Silva

Vistos.

IVAM MENEZES E SILVA ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.

Alegou, em síntese, que em julho de 2021 representantes da companhia ré compareceram em sua residência para realizar a troca do relógio medidor. Ocorre que na data de 19/11/2021 a parte ré realizou corte no fornecimento de energia elétrica junto à unidade consumidora, tendo sido informado ao autor que referido ato foi efetivado com base no TOI lavrado em decorrência de inspeção realizada naquele endereço e consequente cobrança de supostos débitos correspondentes a diferenças de consumo de energia no valor de R\$ 6.701,80. Pleiteou a tutela de urgência para que a ré restabelecesse o fornecimento da energia elétrica no imóvel. Ao final, requereu a confirmação da tutela de urgência, a inexigibilidade do débito. Juntou documentos.

Deferi a gratuidade de justiça e a tutela de urgência (pp. 33/35).

Citada, a ré apresentou contestação e reconvenção (pp. 46/62). Em sede de contestação, sustentou, em linhas gerais, a regularidade na elaboração de TOI em

razão da constatação de irregularidade do medidor, consistente em desvio de energia. O valor cobrado constitui diferença do consumo da unidade. Espera a improcedência dos pedidos. Na reconvenção, pleiteou o pagamento do débito oriundo do TOI. Juntou documentos.

Houve réplica (pp. 93/111) e resposta à reconvenção (pp. 128/139).

É o relatório.

DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos exatos termos do art. 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, eis que, diante da documentação juntada nos respectivos autos, os pontos controvertidos podem ser solucionados, sem mais demora, mediante simples aplicação do direito à espécie.

As pretensões iniciais procedem em parte enquanto a reconvenção improcede.

A hipótese dos autos é recorrente: selecionada determinada unidade consumidora, a concessionária de energia elétrica envia seus prepostos ao local para inspeção do relógio.

Após, afirmando ter encontrado irregularidade no relógio medidor, lavra um relatório, denominado TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) e, não raras vezes, retira o relógio.

Ao depois, com base em dados unilaterais, apura e envia ao consumidor a cobrança de valor que reputa ter sido sonegado em período que considera ter havido irregularidade na medição, com ameaça de interrupção do fornecimento, caso não pague o reclamado.

Em que pese a alegação da parte ré de que o caso dos autos se trata de fraude, não pode o Judiciário compactuar com a conduta da ré, por absoluta insegurança jurídica e ataque aos direitos individuais.

Não se desconhece que pode haver desvio de energia por parte do consumidor, mediante fraude no medidor mas, no caso dos autos, em que pese o estado em que se encontrava o medidor por ocasião da vistoria (ausência de lacres), não é possível a constatação convicta quanto a eventual mau funcionamento.

Fundar-se nelas para se cobrar altas cifras é deixar ao desabrigo de garantias individuais toda a massa de consumidores, potenciais vítimas de desacertos operacionais e administrativos de concessionárias.

Ora, a ré, por seu preposto, acreditando piamente ter havido adulterações no relógio medidor, deveria ter tomado de duas, uma atitude.

A primeira delas, como é intuitivo, seria acionar imediatamente a polícia, vez que se trataria em tese de crime de furto de energia (art. 155, § 3º, do CP). A polícia existe para isso: prevenir, reprimir crimes e apurá-los. E isso 24 horas por dia.

Acionada, caberia a ela promover a perícia no tal medidor e apurar a conduta do consumidor, independentemente de solicitação prévia do consumidor e em tempo não distante da apuração.

Não pretendendo acionar a polícia (ou até cumulativamente, vez que todos têm o dever ao menos cívico de levar ao conhecimento das autoridades competentes o cometimento de um crime), poderia a ré ter tomado a medida administrativa de efetiva realização de perícia, próxima à data da apuração da suposta irregularidade, que deveria ser realizada por terceiro imparcial e habilitado para tal, como o INMETRO, com possibilidade de o consumidor indicar assistente, enfim, em tudo garantindo o contraditório e ampla defesa, expressamente previstos na Constituição Federal, eis que a ré estaria a lançar autêntica acusação de ilícito. Mas isso tudo, antes de apurar o suposto débito.

Entretanto, assim não procedeu.

Preferiu a ré lavrar simplesmente o famigerado T.O.I. e com base somente nele, e em suposta presunção de veracidade de seus atos, cobrar valor que apurou unilateralmente e que, em não sendo pago, resultaria no corte da energia.

Ocorre que ato administrativo emitido por agência reguladora – ANEEL – não tem aptidão para desqualificar os direitos e garantias individuais, dentre eles o sagrado direito ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Ademais, não pode ser imposta ao consumidor a produção de prova da inexistência da fraude, sob pena de se impor a produção da odiosa prova negativa.

Nos termos do artigo 72, inciso II, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL, é direito do

consumidor seja promovida perícia técnica, por terceiro legalmente habilitado, quando o consumidor não concorda com a constatação de irregularidade. Tal regra está em consonância com a legislação consumerista, aplicável ao caso concreto, pois o consumidor, diante da hipossuficiência técnica para provar ausência de fraude no medidor de energia elétrica, deve ter facilitada a produção de provas para tutela de seus direitos, em respeito à máxima *due process of law*. O egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, reiteradamente, vem decidindo que é ônus da fornecedora de energia elétrica comprovar a fraude mencionada no termo de ocorrência de irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Declaratória de Inexigibilidade de Débito, cumulada com pedido de tutela antecipada visando obstar a suspensão do fornecimento, julgada procedente para declarar nula a dívida apurada. APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de energia elétrica. Prestadora que não comprovou que houve fraude na medição da energia elétrica. Ausência de perícia técnica e da realização de outros procedimentos que servissem à fiel caracterização da irregularidade. Inobservância do artigo 72, da Resolução 456/2000 com a nova redação imposta pela Resolução 90/2001 da ANAEEEL. Inversão do ônus da prova imposta ao polo consumidor que afronta as regras consumeristas, manifestamente abusiva a providência. Decisão mantida. Recurso Improvido" (Apelação nº 0047282-25.2010.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL e é apelado FERNANDO PAGLIOTTO, 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador Luís Fernando Nishi, j. 10 de abril de 2014).

Do voto do eminente relator extrai-se o seguinte ensinamento:

"No que concerne ao mérito recursal, ressalvado o entendimento anterior acerca do tema, anoto que a jurisprudência dominante no C. Superior Tribunal de Justiça caminha firmemente no sentido de que, conquanto o artigo 333 do Código de Processo Civil carreie ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o inciso II do mesmo dispositivo legal atribui ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, sendo certo concluir que caberia à concessionária comprovar a existência da alegada fraude, ou, ao menos, da irregularidade no aparelho medidor do fornecimento de energia elétrica, a ensejar a cobrança dos valores lançados com fulcro na Resolução 456 da ANEEL.

Destacam-se os seguintes arestos nesse sentido: 'Caberia à concessionária dos serviços fornecer os elementos de prova das alegações feitas, já que o ônus da prova cabe a quem alega o fato. Não o fazendo, impossível a caracterização da fraude'.

A recorrente, não obstante tenha alegado a existência de fraude no medidor, não procedeu à prova do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado (efetivo consumo de energia e responsabilidade do consumidor pela violação do lacre), ônus que lhe compete, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil.

Correta, pois, a inversão do ônus probatório realizada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, autorizado, para tanto, pelo art. 60, VIII, da Lei 8.078/90 (CDC)".

De conformidade com o art. 72, da Resolução nº 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, a prestadora de serviços de energia elétrica, além de emitir o TOI Termo de Ocorrência de Irregularidade, deve "solicitar os serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição" (inciso II).

O dispositivo restou alterado pela Resolução nº 90/2001, da ANEEL, passando o referido inciso a contar com a seguinte redação: 'promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro habilitado, quando requerida pelo consumidor'.

Assim, se anteriormente à Resolução 90/2001 cabia à prestadora dos serviços, em cumprimento à referida disposição, instruir a sua contestação com laudos ou outros documentos que pudessem atribuir maior robustez ao 'Termo de Ocorrência de Irregularidades'- TOI, independentemente da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

Mesmo se assim não fosse, nos termos da vetusta redação, e do artigo 72, inciso III, da Resolução 456/2000, incumbia à concessionária "implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade", além do Termo de Ocorrência de Irregularidade, tornando evidente que a própria ANEEL considerava insuficiente para comprovação da irregularidade aquele documento.

Também forçoso salientar que a disposição contida na Resolução 90/2001 que condiciona ao pedido do consumidor a realização da perícia no medidor, há de ser considerada abusiva, nos termos do que preceitua o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, mormente por estabelecer inversão do ônus da prova em prejuízo do polo hipossuficiente tecnicamente, contrária a própria sistemática consumerista, de incidência descabida, portanto.

Ademais, se a fornecedora dos serviços imputou o fato e deixou de submeter as instalações da caixa de medição à perícia, antes da sua regularização, assumiu o risco de não produzir a prova indispensável e que só a ela interessava.

Como não o fez, é impossível atribuir ao tomador dos serviços o cometimento da fraude e obrigá-lo a suportar as diferenças de consumo apuradas com base em conclusão unilateral, cuja técnica nem sequer se pode aferir.

As Resoluções ANEEL 456/2000 e a 90/2001 não autorizam um agir sem limites. Ao contrário, estabelecem detalhada forma de atuação, determinando as providências mínimas a serem adotadas pela prestadora, de forma que a apuração das eventuais irregularidades no fornecimento e consumo de energia elétrica seja confiável e segura, sem prejuízo de estarem em completa consonância com as disposições legais que regem as relações de consumo.

Esta Colenda 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo não discrepa do entendimento acima exposto, com posicionamento pacífico sobre a matéria, com o qual passo a aderir, de que o termo de ocorrência de irregularidades não ostenta presunção de veracidade ou de legalidade, devendo a concessionária, em havendo impugnação judicial da sua regularidade, demonstrá-la mediante os meios regulares de direito, principalmente por meio de perícia".

São, portanto, infundadas as alegações da concessionária ré no sentido de que o procedimento por ela adotado estaria em consonância com as regras da ANEEL, tendo em vista que não demonstrou as irregularidades que teriam dado azo à apuração do débito cobrado do consumidor e, pior, sem observância do princípio do contraditório.

No mais, ressalto ser inegável que a relação entre consumidor de energia elétrica e a concessionária é uma relação de consumo. Sendo assim, incide na espécie os ditames do Código Consumerista, dentre eles a proibição de emprego de meios coativos para cobrança de créditos.

Não se pode, assim, efetivar a suspensão do fornecimento de energia se o consumidor não pagar supostos débitos atrasados, mas não faturados.

A solução ora esposada tem o beneplácito da jurisprudência, que, após divergências iniciais, tende a se sedimentar nesse sentido.

Colho do egrégio Tribunal de Justiça, o seguinte julgado de hipótese idêntica, assim ementado, verbis:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERRUÇÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. INADMISSIBILIDADE. APURAÇÃO UNILATERAL NO MEDIDOR DE CONSUMO. NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO OU À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO (31ª Câmara D. Privado, Apelação com revisão nº 995.588-0/4, rel. Des. Francisco Casconi, j. 23.06.2009).

E, ainda:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE IMPUTADA AO CONSUMIDOR EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APURAÇÃO FEITA DE FORMA UNILATERAL. ART. 5º, LV, DA CF E ART. 72, II, DA RESOLUÇÃO 456/00 DA ANEEL. Sentença de procedência parcial da ação mantida. Recursos improvidos" (33ª Câmara D. Privado, Apelação nº 994.138-0/3, rel. Des. Cristiano Ferreira Leite, j. 08.06.09). No mesmo sentido, 26ª Câmara, Apelação nº 1007736008, j. 23.06.09).

A mesma solução tem dado o colendo Superior Tribunal de Justiça para os casos de suposta fraude no medidor. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. FORNECIMENTO. INTERRUÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. [...] É ilegítimo o corte administrativo no fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes do STJ" - RESp 816.689/SP, rel. Herman Benjamin, DJe 17.03.2009.

Dar a solução pretendida pela ré, ou seja, abonar sua conduta, é colocar na mais absoluta insegurança jurídica toda a massa de consumidores que pode ter uma dessas "visitas" dos denominados "técnicos" da ré dizendo simplesmente que o relógio do consumidor está adulterado.

Concluindo, não ficou suficientemente demonstrado nos autos que houve subtração ou desvio no registro de energia elétrica beneficiando-se a unidade consumidora.

Feitas estas considerações, a procedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe, procedendo ainda a pretensão à continuidade do fornecimento, observada a adimplência dos demais débitos. De consequente, a improcedência dos pedidos reconventionais é pressuposto.

No mais, ressalto ser inegável que a relação entre consumidor de energia elétrica e a concessionária é de consumo. Sendo assim, incide na espécie os ditames do Código Consumerista, dentre eles a proibição de emprego de meios coativos para cobrança de créditos.

Por fim, a hipótese é de dano in re ipsa, ou seja, que se depreende do próprio fato, independentemente de outras provas.

Ora, sabido que a situação de corte gera constrangimentos ensejadores de danos morais, pois o bem-estar e a tranquilidade são bens imateriais que foram violados pela conduta negligente da apelante. Ademais, a indevida privação do serviço público de energia elétrica, de caráter essencial e hodiernamente imprescindível à dignidade do cidadão, caracteriza abalo moral.

No tocante ao quantum indenizatório, considerando as funções ressarcitória e

punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro, arbitrase o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra moderado e em sintonia com a jurisprudência.

Quanto aos consectários, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ); os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Observo que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, ex vi da Súmula 326 do Superior Tribunal Justiça.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, assim resolvendo o mérito nos termos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

- 1) declarar a inexigibilidade do débito discutido, relativo aos consumos presumidos do período de 01/2018 a 07/2021;
- 2) condenar a ré a abster-se de suspender/interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora, em relação ao débito aqui discutido, tornando definitivo os efeitos da tutela de urgência;
- 3) condenar a ré ao pagamento de danos morais em favor da parte autora no valor de R\$ 5.000,00, com atualização monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao ano, a partir da data da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Derrotada, condeno a parte requerida no pagamento de honorários em favor do procurador do autor, que arbitro, com fundamento no art. 85, § 2º, CPC, em 20% sobre o valor da condenação, além do valor das custas e despesas processuais.

JULGO IMPROCEDENTES o pedido reconventional, na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, arcará a parte reconvinte com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados, por equidade, em R\$ 1.200,00, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016). Interposto recurso de apelação, deverá a serventia proceder nos termos do art. 1.093 das NSCGJ. Após trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento desta sentença, dando-se baixa definitiva no presente feito junto ao sistema SAJ.

Barretos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA